

1500551-98.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 13,70 gramas de maconha e 10,01 gramas de cocaína, bem como, no mesmo dia, por volta das 20h40, na rua Carlos Rafael Vendramini, 1-161, Pousada da Esperança, nesta cidade, guardava, para fins de tráfico, 42,15 gramas de crack, 1.138,46 gramas de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500551-98.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500551-98.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127479/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 24885168 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2127479 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX WILLIAN FRANCISCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ALEX WILLIAN FRANCISCO foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 10 de maio de 2.022, por volta das 20h00, na rua Pedro Barreiro de Figueiredo, número 11, Pousada da Esperança, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 13,70 gramas de maconha e 10,01 gramas de cocaína, bem como, no mesmo dia, por volta das 20h40, na rua Carlos Rafael Vendramini, 1-161, Pousada da Esperança, nesta cidade, guardava, para fins de tráfico, 42,15 gramas de crack, 1.138,46 gramas de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 95), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 96/100.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 03 de junho de 2.022 (fls. 106/108).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 171 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 210/217).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 223/232, alegando que: 1)- a prova derivada da diligência policial é nula em razão da violação de domicílio pois: 1.1)- ainda que a mãe do acusado, pessoa idosa e com problemas de saúde, tivesse autorizado os policiais a entrarem no imóvel, deve-se considerar que havia quatro policiais do BAEP fortemente armados; 1.2)- segundo entendimento do STJ, o consentimento do morador deve ser documentado e assinado, e deve haver o registro audiovisual de toda a diligência; 2)- eventualmente, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, considerando que as testemunhas Rogério e Natan disseram que o acusado trabalhava como calheiro, não há elementos a apontar que se trata de grande traficante de drogas até porque o réu habitava casa humilde e dormia em um quarto com móveis improvisados, e a moto era "NP", adquirida com recursos que Rogério precisou juntar; 3)- não há razão para fixação de regime inicial fechado. Pediu o acolhimento da preliminar e, alternativamente, a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial semiaberto caso não estabelecida a causa de diminuição de pena e a restituição do telefone celular apreendido.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 35/36 (R\$ 397,00; um telefone celular; um veículo; e drogas) e pelo laudo pericial de fls. 88/93 (uma porção de maconha com peso de 13,70 gramas; trinta e seis porções de cocaína com peso de 10,01 gramas; cento e sessenta e cinco porções de crack com peso de 42,15 gramas; duas porções de maconha com peso de 901,27 gramas; e 169 porções de maconha com peso de 237,19 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Diana Moura Curimbaba, policial militar, relatou que, durante patrulhamento pelo bairro Pousada da Esperança, viu uma motocicleta com a placa adulterada à mão. Tentou se aproximar, mas o condutor iniciou fuga. Ele não obedeceu a ordem de parada e seguiu por dois quarteirões, mas foi abordado. No caminho, o acusado tirou um objeto do moletom e o arremessou. Retornou ao local da dispensa e arrecadou o objeto, notando conter porções de maconha e cocaína ou crack, já prontas para venda. Não se recorda a quantidade de porções. O réu ainda portava cento e quarenta e nove reais em dinheiro. Ele confessou que praticava o tráfico e que iria entregar as drogas em uma praça, a fim de que outro moleque fizesse as vendas. O acusado disse que seus documentos estavam em sua casa, para onde rumaram os policiais. Ele afirmou ainda que, em sua casa, a cerca de três quadras do local onde foi avistado, havia mais drogas. A genitora do réu permitiu o ingresso dos policiais. Vistoriou o quarto do acusado, na presença da mãe dele, e localizou mais porções de maconha e outras drogas, numa cômoda, além de duzentos e quarenta reais em dinheiro embaixo do colchão. O réu foi conduzido com a droga e a motocicleta à delegacia. O entorpecente foi pesado na delegacia, tendo sido constatado que havia cerca de um quilograma de maconha, quarenta e dois gramas de crack e dez gramas de cocaína. Não se recorda o nome da genitora do acusado. Foi até a casa dele para buscar um documento. A busca no quarto se deu em virtude de informação prestada pelo réu, no sentido de que ali havia mais drogas. Tal informação foi prestada quando os policiais chegaram com o acusado em frente à casa dele. Ele também indicou que o entorpecente estava na cômoda. Na sequência, conversou com a mãe dele, tendo ela autorizado a entrada dos policiais e acompanhado a revista. Quando a genitora deu a permissão, um senhor a presenciou, mas não se lembra o nome dele; provavelmente, tratava-se do pai do réu. A genitora assinou um documento autorizando que os policiais entrassem no imóvel. Segundo o acusado, a droga seria destinada a abastecer um ponto de tráfico na praça, onde um moleque fazia as vendas para ele e depois lhe repassava o dinheiro. A abordagem se deu, inclusive, nas proximidades de tal praça, ocasião em que o réu estava indo levar a droga. O celular dele foi apreendido. A respeito da moto, o réu alegou que

a adquiriu como "NP". O veículo não tinha numeração no chassi, a qual havia sido "pinada". Havia pinos de cocaína, dois pacotes grandes de maconha e porções individuais. Foi a placa da moto que chamou a atenção dos policiais. Um dos números houvera sido feito com material de calha e à mão. Dava para ver que era uma moto sem placa. A declaração assinada pela mãe dele foi firmada quando os policiais chegaram. Duas equipes compareceram à casa do réu. Em cada qual, havia quatro policiais. Trabalha no BAEP. A genitora do réu o viu na viatura, mas não se comunicou com o filho. No início da abordagem, o acusado estava sozinho na motocicleta. Ele dispensou as porções de droga no trajeto do acompanhamento policial. A abordagem se deu no período noturno, não se lembra o horário exato. A testemunha Luis Otavio Chaves, também policial militar, afirmou que realizava patrulhamento pelo bairro em questão e viu uma moto, a qual lhe chamou a atenção. No final da placa do veículo, havia uma tarjeta, parecendo material de calha, com confecção manual de número. Deu sinal de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou se evadir. O acompanhamento se deu por cerca cem metros e foram emitidos sinais luminosos e sonoros. Quando a viatura chegou bem próximo, o acusado colocou as mãos na cintura e dispensou um objeto. Ele foi alcançado e abordado. Nada foi encontrado na busca pessoal. A policial Diana arrecadou o invólucro dispensado, tendo sido constatado que, nele, havia porções de cocaína e de maconha. Viu o invólucro posteriormente. Era o comandante da equipe na ocasião. Indagado, o réu confessou que tinha saído de sua casa para ir até uma praça, onde faria o tráfico. Com ele, havia cento e quarenta e nove reais em notas diversas. O réu não portava documentos e informou que eles estavam em sua residência. Deslocou-se com o acusado até a casa dele. Outra equipe permaneceu no local para aguardar o guincho. Em frente ao imóvel, o réu relatou que havia mais drogas em seu quarto e que sua mãe não tinha conhecimento. A genitora acompanhou as buscas. Em meio às coisas do acusado, foram encontradas porções de crack, maconha e dinheiro, todos juntos. O celular dele foi apreendido. Indagado sobre a moto, o réu afirmou que a adquiriu como "NP". A moto havia quebrado e o réu pensou que chamaria menos a atenção fazendo aquela artimanha. Ele explicou que levaria as drogas para uma praça e que trabalhava para um terceiro. O acusado ainda detalhou que recebia entorpecente do terceiro, fracionava-o e o vendia na praça. Tanto que a maior parte da droga estava na casa dele. A mãe dele assinou um documento autorizando o ingresso dos policiais no imóvel. Não se lembra do nome da genitora. O réu confirmou que trabalhava para um terceiro e já era conhecido pela prática do tráfico na região. Ele já houvera sido abordado anteriormente. A abordagem se deu em razão das condições da motocicleta. O acusado estava de capacete e não era possível identificá-lo como condutor. Não havia denúncias de tráfico pairando sobre a casa do réu. Duas equipes participaram das diligências. Uma delas abordou o réu e efetuou a prisão. Uma das equipes permaneceu no local, enquanto a outra foi à casa do acusado. No imóvel, a equipe que se fez presente continha quatro policiais. A declaração da mãe se deu após a comunicação da prisão do filho e de que ele houvera informado haver drogas na casa. Porém, a declaração foi firmada antes da entrada na residência. Viu a policial Diana encontrando o entorpecente no quarto. O quarto era bem pequeno e bagunçado. As drogas estavam em uma cômoda num canto, ao passo que o dinheiro estava em meio a pertences do réu. A cômoda estava bem quebrada e era uma madeira feita manualmente. Havia cama e colchão no quarto. A cômoda era próxima do colchão. Quando da abordagem, não havia garupa na moto. O réu acompanhou a equipe que compareceu em sua casa. Quando os policiais foram conversar com a genitora, ele estava na viatura.

A testemunha Rogerio Ferreira Lopes informou que conhece o réu desde os dezoito anos. Não estava no local do fato no momento da abordagem, pois estava trabalhando. Trabalha com transporte no período noturno. Soube da prisão do acusado posteriormente. O réu trabalhava com calhas e fazendo bicos como servente. Sabe que ele tinha uma moto e que a comprou após juntar dinheiro aos poucos. O acusado trabalhava com Natan, um colega, e mora na Pousada da Esperança. É vizinho dele. Sua casa se situa na rua Carlos Rafael Vendramini. O local da abordagem não é perto da residência. Não sabe o que o réu fazia na rua em que foi abordado. Mora bem ao lado da casa do acusado. Nunca viu polícia na residência dele e nunca ouviu

vizinhos comentaram de envolvimento com o tráfico. A genitora do réu também nunca disse nada. Não recebeu relatos de como se deu a abordagem policial na residência. Pelo que sabe, o réu não estava acompanhado de terceira pessoa quando abordado. A testemunha Natan Vicente Marques afirmou que conhece o réu do trabalho, há três anos. Ele trabalhou em uma empresa de calhas. Arrumou esse serviço para ele. O horário de trabalho é das 07h00 às 17h00. Sabe onde o réu mora. Sabe também que ele foi detido próximo de sua residência, a cerca de uma ou duas quadras. Não presenciou a abordagem policial. Trabalharam juntos naquele dia. Ele disse que iria comer um lanche com a namorada Idinara, à tarde. O réu recebia salário de trezentos reais por semana. Lembra que ele tinha uma moto. Não se tratava de veículo "NP". Soube que ele estava acompanhado de um primo no momento da abordagem. Nunca ouviu informação de envolvimento do acusado com crimes. Ficou surpreso com a prisão dele. Não é cunhado do réu. Vendeu a motocicleta para o acusado. A motocicleta tinha placas. Não sabe por qual razão as placas estavam adulteradas. Vendeu o veículo e entregou os documentos, que estavam para vender. Ficou pouco tempo com a moto, revendendo-a assim que a adquiriu. Não se recorda quanto tempo antes da prisão fez a venda. Não se lembra da placa.

A testemunha Tamara Cristina Francisco afirmou que os policiais foram em sua casa na data da prisão de seu filho. Estava dormindo e a ação ocorreu por volta das 21h00. Pensou que era seu filho era quem estava entrando, pois os cachorros começaram a latir. Perguntou quem era e ouviu responderem que se tratava da polícia. Viu os policiais já em sua cozinha com uma lanterna. Ficou assustada e perguntou por qual motivo eles ali estavam. Os policiais responderam que vieram buscar um documento de Alex. Disse-lhes que o pegaria. Contudo, os policiais afirmaram que eles próprios iriam pegá-lo. Os policiais adentraram no quarto do réu, pegaram documento e bagunçaram tudo. Eles lhe entregaram um documento dizendo que autorizava a entrada no quarto. Assinou-o. Eles não lhe pediram previamente para entrar. Quando notou, os policiais já estavam na cozinha. Seu marido estava presente e percebeu a entrada não autorizada dos policiais. Ele é padrasto de Alex. Os policiais encontraram dois "paieiros", "papelotinhos", e disseram que era indício de que o réu era usuário. Entraram na casa uma policial feminina, um policial mais alto, outro mais baixo e um terceiro ainda mais baixo. Os policiais estavam armados com espingarda grande. Eles não lhe mostraram dinheiro nem balança, porque não havia tais bens na casa. Não acompanhou a revista no quarto. Ficou na cozinha com um policial. Sua casa é pequena e tem três cômodos. Somente a policial feminina entrou no quarto. Ela fuçou tudo e trouxe apenas esse "negocinho". Nunca recebeu qualquer informação de envolvimento de seu filho com o tráfico. Ele trabalhava como "calheiro" e é esforçado. Apenas na ocasião, descobriu que o réu fumava maconha. Ele sempre trabalhou e não é traficante.

Interrogado em juízo, o réu declarou que estava em casa com seu primo. Fumaram baseado de maconha. Seu primo disse que tinha de ir embora. Falou-lhe que iria levá-lo e que depois iria comer um lanche com sua namorada. Saiu de casa e, logo que subiu duas quadras, foi abordado pela polícia. Os policiais perguntaram se tinha droga. Respondeu-lhes que tinha apenas uma "trouxinha", a qual iria fumar mais tarde. Os policiais lhe disseram que estava preso e o colocaram na viatura. Outra viatura chegou e depois foi até sua casa. Os policiais revistaram o imóvel. Não foi levado até sua residência. Dias antes, os policiais o haviam abordado e o enquadrado, pois tinha ido na "biqueira" comprar baseado para seu consumo, junto com dois outros usuários. Os policiais nada encontraram, agrediram-nos e os soltaram. Foi embora para sua casa e, dois dias depois, "aconteceu esse ocorrido". Na data do fato, chegou do serviço e estava na sua casa. Saiu com seu primo para comprar baseado. Fumaram a droga. Em seguida, foi levar seu primo embora, quando então foi enquadrado pela polícia. No momento de sua prisão, estava com seu primo, que era menor de idade. Os policiais encontraram consigo uma "trouxinha" de cinco reais, a qual fumaria antes de comer lanche com sua namorada. Eles disseram que iriam em sua casa buscar seu RG e que desceria para delegacia, para prestar depoimento do dia anterior, quando foi testemunha. Como não falou quem era o traficante "de lá", os policiais disseram que iria descer para a delegacia. Na data da prisão, não foi agredido. Foi agredido na ocasião anterior, quando negou-se a

dizer quem era o traficante. Em sua casa, não havia droga, apenas uma segunda "trouxinha", porção pequena. Os mesmos policiais que o abordaram dois dias antes foram os que o prenderam. Naquela oportunidade, estava na biqueira e conversava com dois meninos. A viatura passou e os enquadrou. Todos disseram que eram usuários. Os policiais pediram que apontassem o traficante. Falou-lhes que não iria caguetar ninguém porque, em sua vila, quem faz isso morre. Na delegacia, os policiais apareceram com uma sacola cheia de drogas. Seu primo foi dispensado na hora porque era "de menor". Disse para os policiais que a "trouxinha" era sua, e não de sua primo. Eles o colocaram na viatura e o levaram para a delegacia, enquanto uma outra viatura foi até sua casa.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas defesas pessoal e técnica.

A alegação preliminar de violação de domicílio não merece prosperar.

É razoável entender ser imprestável o documento acostado a fls. 37, para servir de prova do consentimento da genitora do acusado para ingresso em sua casa.

Afinal, ao saber da notícia da prisão do filho e notar a presença de quatro policiais militares armados em sua porta, a moradora pode ter se sentido acuada, não lhe restando outra alternativa a não ser assinar o documento.

Nada obstante, o ingresso dos policiais na residência do acusado não se deu de forma inconstitucional.

Isto porque os policiais militares foram uníssonos na versão de que o réu confessou que possuía mais drogas em sua casa, indicando, inclusive, que o entorpecente estava numa cômoda em seu quarto e que ali a fracionava para a posterior venda numa praça, local conhecido como ponto de tráfico.

Portanto, havia claros indícios de que, no imóvel, estava presente material cuja guarda configurava crime, tendo-se, pois, hipótese de flagrante delito.

Ademais, a conduta do acusado, consistente em tentar se subtrair à abordagem policial e dispensar drogas já embaladas de forma própria ao comércio, provavelmente logo após sair de sua casa (ante a proximidade do local da abordagem e a residência), robustecem aqueles indícios.

Já a versão do acusado, no sentido de que estava apenas na posse de uma pequena porção de maconha e de que nada disse aos policiais a respeito da presença de mais entorpecente em sua casa, não goza de verossimilhança qualquer.

Afinal, fosse isso verdade, a demonstração do alegado poderia ter sido feita de forma bastante simples, bastando que fosse arrolado como testemunha o primo, o qual, segundo o informado, estava em sua companhia quando da abordagem.

Enfim, antes mesmo da colheita da autorização escrita da mãe do réu, os fatos que até então se desenrolaram já legitimavam que a Polícia Militar adentrasse na casa dele, ainda que sem consentimento do morador.

Acresça-se que, se os policiais dali se retirassem para obter mandado de busca e apreensão ou mesmo se permanecessem em frente ao imóvel mas retardando a diligência, certamente o corpo de delito poderia ter sido destruído.

Isto porque, apesar de o réu já estar detido, havia, na ocasião, outros dois moradores no imóvel (a mãe e o padasto), inexistindo prova de que eles não soubessem da presença da droga no quarto de Alex.

Aliás, o contrário é o que se pode presumir pois, de um lado, segundo o dito pela própria genitora, testemunha Tamara, a habitação é pequena e composta por poucos cômodos e, de outro, havia ali pouco mais de um quilo de maconha, entorpecente que exala odor forte e característico.

Não se descarta, portanto, que, notando a presença da polícia do lado de fora, os moradores resolvessem se desfazer do material ilícito ou ocultá-lo, visando evitar que o próprio filho ou enteado viesse a ser preso por crime de tráfico.

Portanto, afasta-se a alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Quanto ao tema de fundo, o fato e sua autoria estão bem demonstrados.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, os quais detiveram o réu na via pública logo após ele ter dispensado uma sacola contendo porções de entorpecentes prontas para venda no varejo, bem como na posse de dinheiro. Ainda de acordo com os agentes públicos, o acusado lhes informou que, em sua casa, havia mais droga e, de fato, no quarto dele, foram achadas outras

porções de drogas e dinheiro.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

A propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Nesse sentido, aliás, é que deve ser interpretado o depoimento da testemunha Tamara, que é mãe do réu e afirmou de forma inverídica que, na residência, foram encontradas apenas duas pequenas porções de maconha.

Nem se alegue que os policiais responsáveis pela prisão são suspeitos, por terem abordado o acusado dois dias antes e tido, desde então, animosidade para com ele, em razão de o mesmo ter se negado a apontar quem era o traficante da "biqueira" onde havia ido comprar droga.

Uma vez mais, insista-se que, fosse isso verdade, o réu poderia comprovar sua alegação arrolando como testemunhas aqueles outros dois "meninos" que estavam consigo naquele momento, e que igualmente teriam sido agredidos pelos policiais militares.

Aliás, estando os três juntos, a mesma represália alegadamente sofrida pelo réu com sua posterior prisão injusta por tráfico deveria ocorrer também em relação àqueles outros dois, pois estavam na mesma situação em que o acusado, ou seja, de simples usuários que teriam se negado a apontar quem era o traficante.

Mas disso não se têm notícias muito menos comprovação.

Logo, o teor da denúncia está bem comprovado.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico, bastando atentar para as quantidades de drogas encontradas, bem como para a confissão informal, a qual guarda estreita correlação com a apreensão de porções de entorpecentes já fracionados para venda no momento em que o agente estava perto de uma praça onde, segundo ele próprio, o material seria entregue ao vendedor do varejo, e também com a apreensão de maior quantidade de maconha e crack na residência, local utilizado para guarda e fracionamento do material ilícito.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde e a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao revés, impõe-se a condenação na forma proposta na denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não tem antecedentes criminais (fls. 41/42).

No entanto, em razão da grande quantidade de maconha e da razoável quantidade de crack, a par, ainda, de cocaína, apreendidas, e observado o disposto no art. 42 da Lei Antidrogas, eleva-se a pena base na proporção de um quinto, resultando em seis anos de reclusão, mais seiscentos dias-multa.

Presente, no entanto, a atenuante da confissão, ainda que tenha se dado de modo informal.

Assim, reconduz-se a pena para o mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Não é possível retroceder o "quantum" da reprimenda para montante inferior a tal limite, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável ao caso a causa de diminuição de pena nele estabelecida. Com efeito, a par da primariedade e ausência de antecedentes, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

Acrescente-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecente. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Diminuição da pena. Benefício negado. Indicação de atividade criminosa. Situação não demonstrada por dados concretos. Valoração em torno da própria conduta pela qual foi apenado. Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Reprimenda base fixada no mínimo legal. 1 – A exclusão da causa minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve basear-se em dados concretos, não podendo o juiz se valer, para tanto, da própria conduta na qual o réu foi apenado para afirmar a existência de 'atividade criminosa'. 2 – Na espécie, as circunstâncias judiciais, valoradas em favor do réu, permitiram a fixação de pena no mínimo legal, razão por que se afigura incoerente impedir a diminuição sem elementos outros que realmente comprove ser o caso desmerecedor da benesse legal. 3 – Recurso provido, para reduzir a pena em 2/3 (dois terços)." (STJ, 6ª Turma, REsp n. 1.085.039/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 08/09/009) (em TJSP, Apelação n. 0023252-62.2013.8.26.0071).

No mesmo sentido:

"Habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Fundamentação inidônea. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade. Precedentes. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio do 'in dubio pro reo'. Precedentes. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar o óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo a fixação do 'quantum' ser realizada pelo juízo do processo de origem, ou, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, pelo juízo da execução da pena."

(STF, 2ª Turma, HC n. 103225/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 21/11/2011) (idem).

Aliás, em recente decisão, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reformou entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de restabelecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim decidiu o eminente Ministro:

"Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito, essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das

decisões judiciais. Da leitura da decisão transcrita, não vislumbro fundamentação apta a justificar a não aplicação da causa de diminuição. O Tribunal de origem destacou que a paciente 'se dedicava à atividade ilícita de modo habitual e reiterado, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e que das circunstâncias em que foi surpreendida pelos policiais militares, isto é, por volta de 1h25 (...) tudo a indicar que não era principiante e fazia do comércio ilícito seu meio de vida, emergindo inegável, portanto, o seu envolvimento com atividade criminosas, notadamente com traficantes de maior porte, seus fornecedores ou patrões." Contudo, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a provar a afirmativa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, especialmente quando se observa que o Parquet somente arrolou como testemunhas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ora, a configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos e não de meras ilações, sem correspondência fática. O envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, como apontou a decisão atacada, pressupõe que o agente, no mínimo, pratica ou praticou diversos atos ou, ao menos, está inserido em grupo/organização direcionada ao crime. Entretanto, o ônus de provar tais elementos que afastam a redutora é da acusação, não cabendo ao magistrado colher elementos extraprocessuais para imputar uma reprimenda mais severa, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, o caso trata de condenação pelo tráfico de 7,67 (sete gramas e sessenta e sete decigramas) de maconha, mais 4,5 (quatro gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, ou seja, não se trata de quantia vultosa como afirmado no acórdão proferido pelo TJSP. Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem o paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de traficante primária e não há nenhuma indicação de maior envolvimento em atividades ilícitas." (Habeas Corpus n. 137458/SP, j. 29/09/2016).

No caso concreto, mesmo o teor da confissão informal não aponta para conclusão de que se está diante de agente que se dedica a atividade criminosa ou que integra organização criminosa, na medida em que não se evidenciou há quanto tempo ele vinha tomando parte de um organograma voltado à distribuição de droga, com a tarefa específica de guarda, fracionamento e distribuição de entorpecente visando repasse ao responsável pela venda do produto ilícito no varejo.

Saliente-se, à propósito, que a quantidade de dinheiro apreendida foi pequena. Tampouco a alegação de que o réu dirigia uma motocicleta com placa e número de chassi adulterados presta-se a arredar o privilégio perseguido pela defesa. Quanto à adulteração da placa, nota-se tratar-se de algo feito de forma bastante grosseira, desde logo percebido por qualquer observador.

No tocante à adulteração do número do chassi, não se tem prova mais consistente a respeito, não se podendo perder de vista que não consta dos autos perícia dos caracteres em questão.

A tudo some-se que, segundo entendimento atual dos Tribunais Superiores, a mera quantidade de entorpecente, por si só, não indica que o acusado se dedica a atividade criminosa.

Cabível o privilégio, deve-se deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, a fim de evitar a aplicação simultânea da quantidade de drogas como fator prejudicial em duas fases da dosimetria de pena, conforme tem entendido aqueles mesmos Tribunais Superiores.

Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Em que pese o montante da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Como já explicitado quando do aumento da pena base, a quantidade robusta de drogas apreendidas demonstra o maior desvalor da conduta, sendo o regime mais gravoso o único capaz de propiciar a resposta adequada às finalidades de retribuição e prevenção da pena.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de

direitos.

O disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem repercussão na redefinição do regime inicial de cumprimento da pena pois, ante à maior reprovabilidade da conduta derivada da apreensão de grande quantidade de drogas, a questão atinente à progressão de regime deverá ser melhor sopesada pelo juízo das execuções criminais, inservível, no momento, a simples constatação de que cumprido o critério objetivo.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Alex Willian Francisco como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao telefone celular apreendido, é bem daqueles cuja posse, por si só, não configura fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, o bem deverá ser doado ou inutilizado, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu custodiado durante a instrução. Agora, condenado a cumprir pena relativamente longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão há de permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a periculosidade demonstrada por agente que traz consigo e guarda grande quantidade de droga.

Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA